

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1411/2554

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
นายวราห์หรือจิว อุลิศ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 3, มาตรา 75, มาตรา 76, มาตรา 227 วรรคแรก (เดิม), มาตรา ,
มาตรา 317 วรรคสาม

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง

ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายที่ 1 มีอายุเพียง 13 ปีเศษ เมื่อจำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 ในขณะที่ผู้เสียหายที่ 1 มีอายุไม่เกินสิบห้าปีและมีใช้ภริยาของจำเลยไม่ว่าผู้เสียหายที่ 1 จะยินยอมให้จำเลยกระทำชำเราหรือไม่ จำเลยย่อมมีความผิด ตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคแรก (เดิม) และการที่จำเลยพาผู้เสียหายที่ 1 ไปกระทำชำเราที่บ้านของ ส. ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดอำนาจปกครองของผู้เสียหายที่ 2 โดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร จำเลยมีความผิดฐานพรากเด็กอาจไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาตาม ป.อ. มาตรา 317 วรรคสามด้วย แต่ขณะกระทำ ความผิดจำเลยยังเป็นวัยรุ่นกระทำด้วยความผิดด้วยความคึกคะนอง ทั้งผู้เสียหายที่ 1 ยินยอมให้จำเลยกระทำชำเรา ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำ ความผิดมาก่อนและพฤติการณ์แห่งคดียังไม่ร้ายแรงนัก ที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยฐานกระทำชำเราจำคุก 12 ปี และฐานพรากเด็กไปเพื่อการอนาจาร จำคุกไม่เกิน 8 ปี โดยไม่รอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยนั้น เห็นว่า เป็นการกำหนดโทษที่หนักเกินไปและการให้จำเลยต้องรับโทษจำคุกไปเสียเลยนั้นย่อมไม่เป็นผลดีแก่จำเลยและสังคม จึงเห็นสมควรกำหนด

โทษจำคุกเสียใหม่และให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีด้วยการรอลงโทษให้
จำเลย แต่เพื่อให้จำเลยหลบจำ จึงเห็นสมควรคุมความประพฤติของจำเลยด้วย

ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาได้มี พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.อ. (ฉบับที่
21)ฯ มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 75 และ 76 แห่ง ป.อ. และให้ใช้ความใหม่
แทน คดีนี้ขณะจำเลยกระทำความผิด จำเลยอายุสิบเจ็ดปีเศษ การลดมาตราส่วนโทษ
จะต้องลดตามมาตรา 76 (เดิม) และมาตรา 75 (ที่แก้ไขใหม่) ซึ่งกฎหมายที่แก้ไข
ใหม่เป็นคุณมากกว่า จึงต้องใช้กฎหมายที่แก้ไขใหม่ในส่วนที่เป็นคุณบังคับแก่จำเลย
ตาม ป.อ. มาตรา 3 ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นอ้างและแก้ไขโดยปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องตาม ป.วิ.อ.
มาตรา 395 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 277, 317

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
277 วรรคแรก, 317 วรรคสาม เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ฐานข่มขืนกระทำชำเรา จำคุก 12 ปี ฐานพรากเด็กไปเพื่อการอนาจาร จำ
คุก 8 ปี รวมจำคุก 20 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

อนึ่ง ข้อเท็จจริงปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของจำเลยว่า จำเลยเกิดวันที่ 29 มีนาคม 2521 ขณะกระทำความผิดจำเลยจึงมีอายุเพียง 17 ปีเศษ ซึ่งเป็นเยาวชน คดีจึงอยู่ในอำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว กรณีจึงเป็นเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอายุปรากฏขึ้นในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จึงให้โอนคดีไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเพื่อพิจารณาพิพากษาต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 15

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า นาง ส. ผู้เสียหายที่ 1 เป็นบุตรของ นาย อ. ผู้เสียหายที่ 2 กับนาง ร. เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2525 ตั้งแต่ปี 2533 ผู้เสียหายที่ 1 มีนางบัวคำ หรือไล กล้าหาญ เป็นผู้ดูแลและพักอาศัยอยู่กับนางบัวคำที่หมู่บ้านรัตนธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำเลยพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านรัตนธิเบศร์ด้วยโดยมีบ้านของบุคคลอื่นกันอยู่ 2 หลัง จำเลยกับผู้เสียหายที่ 1 รู้จักกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายที่ 1 เป็นพยานเบิกความว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่เท่าใดจำไม่ได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2539 ขณะนั้นผู้เสียหายที่ 1 อายุ 13 ปีเศษ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนจำเลยเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำเลยชวนผู้เสียหายที่ 1 ไปเที่ยวงานที่โรงเรียนของจำเลย นัดพบกันที่หน้าปากซอยทางเข้าหมู่บ้านรัตนธิเบศร์ในตอนเช้า แล้วจำเลยกลับพาผู้เสียหายที่ 1 ไปที่บ้านของนายสายชล สุทธิกุล เพื่อนของจำเลยที่หมู่บ้านการเคหะนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำเลยพาผู้เสียหายที่ 1 เข้าไปในห้องนอนแล้วกอดจูบ บังคับถอดเสื้อผ้าผู้เสียหายที่ 1 ออกแล้วข่มขืนกระทำชำเรา หลังเกิดเหตุจำเลยขู่ผู้เสียหายที่ 1 ให้ทำ

ตามที่จำเลยบอก มิฉะนั้นจำเลยจะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นแก่นางบัวคำ จนช่วงเย็นจำเลยพาผู้เสียหายที่ 1 ไปส่งใกล้บ้าน จากนั้นจำเลยนัดผู้เสียหายที่ 1 ไปพบและกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 ที่บ้านดังกล่าวอีกหลายครั้ง เห็นว่า เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับผู้เสียหายที่ 1 แม้จำเลยจะเบิกความปฏิเสธว่าจำเลยเป็นเพื่อนกับผู้เสียหายที่ 1 ไม่เคยไปไหนด้วยกันสองต่อสองและไม่เคยร่วมประเวณีกับผู้เสียหายที่ 1 แต่นายสายชลพยานโจทก์ซึ่งเป็นเพื่อนกับจำเลยเบิกความว่า ผู้เสียหายที่ 1 เป็นคนรักของจำเลย และไม่มีเหตุผลใดที่ผู้เสียหายที่ 1 จะเอาความเท็จกล่าวหาจำเลยในเรื่องที่ผู้เสียหายที่ 1 เป็นฝ่ายต้องอับอาย ทั้งจำเลยเบิกความรับว่า ขณะจำเลยไปด้วยกันกับผู้เสียหายที่ 1 บนรถยนต์กระบะของจำเลย จำเลยมีเหตุทะเลาะกับผู้เสียหายที่ 1 จนผู้เสียหายที่ 1 ไปร้องทุกข์กล่าวหาว่าจำเลยทำร้ายร่างกาย และในคดีที่จำเลยถูกฟ้องว่าหมิ่นประมาทผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพนั้น เหตุเกิดเพราะจำเลยพบผู้เสียหายที่ 1 เดินกับนายเอกแล้วจำเลยเข้าไปพูดกับนายเอกว่า "จำเลยเป็นสามีเก่าของผู้เสียหายที่ 1" อันมีลักษณะเป็นการหึงหวงผู้เสียหายที่ 1 ที่ไปเดินกับชายอื่นพฤติการณ์ตามทางนำสืบของจำเลยดังกล่าวเป็นการเชื่อมกับคำเบิกความของผู้เสียหายที่ 1 ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า จำเลยคบหากับผู้เสียหายที่ 1 ในฐานะคนรักและมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวถึงขั้นร่วมประเวณีกันตามที่ผู้เสียหายที่ 1 เบิกความ แต่ที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 โดยผู้เสียหายที่ 1 ไม่ยินยอมนั้น เห็นว่า ผู้เสียหายที่ 1 อ้างว่าจำเลยชวนผู้เสียหายที่ 1 ไปเที่ยวงานโรงเรียนของจำเลย จนผู้เสียหายที่ 1 ไม่ไปเรียนหนังสือและไปด้วยกันกับจำเลย เมื่อจำเลยพาผู้เสียหายที่ 1 ไปที่บ้านนายสายชล ไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายที่ 1 ขัดขืน และผู้เสียหายที่ 1 เบิกความรับว่า ขณะเกิดเหตุบ้านข้าง ๆ มีคนอยู่ หากร้องขอให้คนช่วย คนข้างบ้านก็จะได้ยิน แต่ผู้เสียหายที่ 1 ก็มีได้กระทำเช่นนั้น ที่ผู้เสียหายที่ 1 อ้างว่า ถูกจำเลยข่มขู่ว่าหากไม่ทำตามจำเลยจะบอกนางบัวคำทำให้ผู้เสียหายที่ 1 กลัวก็ไม่มีเหตุผล ทั้งหลังเกิดเหตุผู้เสียหายที่ 1 ก็ไม่มีพฤติการณ์ผิด

ปกติให้นางบัวคำซึ่งเป็นผู้ดูแลทราบจนเวลาผ่านไปหลายปี จนกระทั่งผู้เสียหายที่ 1 กับจำเลยมีเหตุขัดแย้งกันเมื่อประมาณปลายปี 2544 หลังเกิดเหตุคดีนี้ตาม พฤติการณ์ที่จำเลยกับผู้เสียหายที่ 1 มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันเป็นเวลาประมาณ 5 ปี และผู้เสียหายที่ 1 เบิกความยอมรับว่า หลังเกิดเหตุผู้เสียหายที่ 1 กับจำเลยมีความสัมพันธ์ทางเพศกันประมาณ 30 ครั้ง เชื่อได้ว่า ผู้เสียหายที่ 1 ยินยอมร่วม ประเวณีกับจำเลยโดยสมัครใจ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้เสียหายที่ 1 เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2525 เหตุคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2539 ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายที่ 1 มีอายุเพียง 13 ปีเศษ เมื่อจำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 ในขณะที่ผู้เสียหายที่ 1 มีอายุยังไม่เกินสิบห้าปีและมีใช้ภริยาของจำเลย ไม่ว่าผู้เสียหายที่ 1 จะยินยอมให้จำเลยกระทำชำเราหรือไม่ จำเลยย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง และการที่จำเลยพาผู้เสียหายที่ 1 ไปกระทำชำเราที่บ้านของนายสายชล ถือว่า เป็นการลวงละเมิดอำนาจปกครองของผู้เสียหายที่ 2 โดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร จำเลยจึงมีความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม อีกกระทงหนึ่งด้วย แต่ขณะกระทำความผิดจำเลยยังเป็นวัยรุ่นกระทำความผิดด้วยความตึกคะนองตามประสาวัยรุ่น ทั้งผู้เสียหายที่ 1 ยินยอมให้จำเลยกระทำชำเรา ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำความผิดมาก่อน ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่ร้ายแรงนักที่ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยฐานข่มขืนกระทำชำเรา จำคุก 12 ปี และฐานพรากเด็กไปเพื่อการอนาจาร จำคุก 8 ปี โดยไม่รอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยนั้น เห็นว่า เป็นการกำหนดโทษที่หนักเกินไป และการให้จำเลยต้องรับโทษจำคุกไปเสียเลยนั้น ย่อมไม่เป็นผลดีแก่จำเลยและสังคม จึงเห็นสมควรกำหนดโทษจำคุกเสียใหม่ และให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีด้วยการรอกการลงโทษให้จำเลยสักครั้งหนึ่ง แต่เพื่อให้จำเลยรู้สึกหยาบจำจึงเห็นสมควรคุมความประพฤติของจำเลยด้วย และในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551 มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 75 และ 76 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความใหม่แทน คดีนี้ขณะจำเลยกระทำความผิด จำเลยอายุสิบเจ็ดปีเศษ การลดมาตราส่วนโทษจะต้องลดตามมาตรา 76 (เดิม) และมาตรา 75 (ที่แก้ไขใหม่) ซึ่งกฎหมายที่แก้ไขใหม่กำหนดให้ศาลต้องลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่ง มิใช่เป็นเรื่องที่ศาลเห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษตามกฎหมายเดิม กฎหมายที่แก้ไขใหม่เป็นคุณมากกว่า จึงต้องใช้กฎหมายที่แก้ไขใหม่ในส่วนที่เป็นคุณบังคับแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นอ้างและแก้ไขโดยปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

อนึ่ง แม้ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550 มาตรา 3 ยกเลิกความในมาตรา 276 และ 277 และให้ใช้ข้อความใหม่แทน แต่กฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลยจึงต้องใช้กฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดบังคับกับจำเลยทั้งสอง

พิพากษาลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก (เดิม), 317 วรรคสาม จำเลยอายุสิบเจ็ดปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษที่จะลงแก่จำเลยกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 (ที่แก้ไขใหม่) ฐานข่มขืนกระทำชำเราจำคุก 3 ปี ฐานพรากเด็กไปเพื่อการอนาจาร จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 6 ปี อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 106 ให้รอกการลงโทษจำคุกไว้ 3 ปี และคุมความประพฤติของจำเลยไว้มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้จำเลยฟัง โดยกำหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติให้จำเลยไปรายงานตัวต่อ

พนักงานคุมประพฤติปีละ 3 ครั้ง ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควร
กับให้จำเลยละเว้นการประพฤติได้อันอาจนำไปสู่การกระทำความผิดทำนองนี้อีก
และให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุม
ประพฤติและจำเลยเห็นสมควรเป็นเวลา 30 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(วิชา มั่นสกุล-อดิศักดิ์ ทิมมาศย์-นพวรรณ อินทร์มพรรย์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ